



---

**DISCIPLINAS COMPLEMENTARES**  
AGOSTINHO ZECHIN  
DIREITO DO TRABALHO  
AULA 2

---

**ROTEIRO DE AULA**

---

**Sumário**

2. Fontes do direito do trabalho

2.1. Conceito de fonte do direito:

2.2 Fonte material

2.3 Fonte formal

3. Princípios do direito do trabalho

3.1 princípio da proteção ao trabalhador

3.2 princípio do “in dubio pro operário” / “in dubio pro misero”

3.3 princípio da norma mais favorável

3.4 princípio da condição mais benéfica ao trabalhador

3.5 Princípio da primazia da realidade (primazia da realidade sobre a forma)

4. Sujeitos do direito do trabalho

4.1 Conceito de trabalhador:

4.2 Questão teleológica do direito do trabalho

4.3 Conceito jurídico de empregado e seus requisitos:

- **Fontes do direito do trabalho**

- **Conceito de fonte do direito:**

- É a origem do direito

- **Fonte material**

- O conjunto de fenômenos sociais que contribuem para a formação da matéria do Direito (fato social relevante)
- Ex. Revolução Industrial (fenômeno que afetou, por exemplo, o limite na duração diária do trabalho; ademais, teve como fonte, os artigos de lei e CF –fontes formais)

- **Fonte formal**

- Meios pelos quais se estabelece a norma jurídica, ou seja, a materialização do Direito (direito ganhando forma)
- Ex. CF/88; Lei;

- A) fontes formais autônomas

- As normas delas resultantes provêm dos próprios destinatários
- Destinatários criando as normas
- Ex. Convenção Coletiva de trabalho; Acordo coletivo do trabalho

- B) fontes formais heterônomas

- As normas delas resultantes provêm de órgãos estatais
- Agentes estranhos do destino da norma
- Ex. Lei; sentenças normativas; CF/88

- **Princípios do direito do trabalho**

- Princípios são enunciados genéricos com, pelo menos duas, finalidades

- Auxiliam o criador da norma jurídica
- Auxiliam o intérprete da norma jurídica
- ex. princípio geral da isonomia: todos devem ser tratados igualmente
- há princípios gerais e específicos

- A) princípio da proteção ao trabalhador**

- Proteção da parte mais fraca da relação jurídica
- Confirma o princípio da isonomia material
- Intervenção estatal nas relações trabalhistas; colocando, inclusive, alguns obstáculos na autonomia privada dos trabalhadores
- Tratar empregado e empregador de forma diferentes

- Não se fere o princípio da isonomia, já que está aplicando a vertente material
- Empregador como hipersuficiente e empregado como hipossuficiente (por isso se busca a compensação)
- O princípio “b, c e d”, abaixo, são decorrentes deste

## Bloco 2

### B) princípio do “in dubio pro operário” / “in dubio pro misero”

- Na dúvida, a solução será a favor do operário
- Em duas ou mais interpretações viáveis de uma norma jurídica, o intérprete deve optar pela interpretação mais favorável ao empregado
- ex. em convenção coletiva de trabalho há cláusula que diz que para o empregado que estiver em vias de se aposentar, há estabilidade de 12 meses; empregado dentro dos 12 meses para se aposentar, em prazo mínimo de aposentadoria, é despedido; o empregador diz que, nos prazos máximos, está a mais de 12 meses; a interpretação adotada deve ser a mais favorável ao empregado
- Não se aplica para o âmbito probatório (não se aplica na valoração de provas)
- Trata-se de princípio de direito material e não processual (ex. empregado ajuíza reclamação para postular horas extras; na contestação, a empresa aduz que não houve horas extras; a empresa junta documentos comprovando; o empregado traz testemunhas; empate nas provas; o juiz não pode invocar o princípio para conceder as horas extras; situação deve ser resolvida por regras processuais do ônus da prova)
- Trata-se de regra de hermenêutica (alcance da norma jurídica)
- Não confundir com o in dubio pro reo ou com o in dubio pro debitoris (ainda que possuam a mesma origem: proteção da parte mais fraca da relação jurídica: réu e devedor)

### C) princípio da norma mais favorável

- O ápice da pirâmide de Kelsen, no direito do trabalho, é mutável: conforme a norma mais favorável ao trabalhador
- Aplica-se quando existirem **mais de uma norma possível** ao caso
- Ex. **Art. 620 da CLT (redação antiga)** - As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.<sup>1</sup>
- Teorias para a forma de interpretação da norma mais favorável:
  - **Teoria do conglobamento (teoria da inscindibilidade)**
    - Deve-se aplicar a norma como um bloco
    - ex. ao aplicar uma Convenção Coletiva em detrimento de um Acordo Coletivo, por aquela ter uma cláusula mais favorável, deverá ser feita a aplicação da Convenção toda, e não apenas de uma ou outra cláusula mais favorável

<sup>1</sup> Redação atual: Art. 620 da CLT - As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho

- Norma indivisível (mesmo que o Acordo tenha alguns aspectos mais positivos; não pode pegar um pouco da Convenção e um pouco do Acordo)

- Não aplicar por partes

- **Teoria majoritária**

- **Súmula nº 51, II do TST** – “Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.”

- **Súmula 288, II do TST** – “ Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro.”

- **Teoria da acumulação (teoria atomística)**

- “Escolhe-se” o que for mais favorável de cada norma

- Utiliza-se partes de cada norma, no que cada uma for mais favorável

- Nota-se que isso cria uma terceira norma, com elementos de extraídos de cada norma

- Teoria minoritária (pouca aceitação)

- **Teoria do conglobamento por institutos (conglobamento orgânico; conglobamento mitigado)**

- Utiliza-se o bloco de institutos

- Ex. regra A contém bloco de férias (bloco abrange 1/3, 30 dias; etc.) e de duração do trabalho bloco abrange 60% de horas extras; 8 horas diárias; 44 horas semanais, etc); regra B contém bloco de duração do trabalho (bloco abrange 60% de horas extras; 6 horas diárias; 30 horas semanais, etc.) e bloco de férias (25 dias de férias; 2/3); note que a norma A é mais favorável no número de dias, enquanto a norma B no acréscimo do salário de 2/3, no que tange às férias; a teoria diz que deve escolher a regra de bloco do instituto totalmente (ou o bloco das férias de A ou o bloco de férias da B), mas permite que se pegue o bloco de outros institutos em normas distintas; no caso em questão, poderia pegar o bloco de férias de A e pegar o bloco de duração do trabalho de B

### **Bloco 3**

- Octavio Bueno Magano justificava que a teoria estava expressamente prevista no dispositivo:

- ❖ **Art. 3º da Lei 7.064/82** – “A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços:

- II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria. “

❖ Obs. Essa lei não trata apenas de empregado transferido para trabalhar no exterior (“Art. 1º Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior”).)

❖ Somente o empregado de empresa brasileira, transferido para trabalhar no exterior para esse mesmo empregador, pode realizar a escolha da teoria em questão

❖ Já o empregado contratado por empresa estrangeira para trabalhar diretamente no exterior, não possui esse direito de optar (deve utilizar a norma do local de trabalho)

❖ Lei 7.064/82

“Art. 1º - Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. “

#### CAPÍTULO II - Da Transferência

“Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se transferido:

I - o empregado removido para o exterior, cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro;

II - o empregado cedido à empresa sediada no estrangeiro, para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador brasileiro;

III - o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior.”

“Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços:

I - os direitos previstos nesta Lei;

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria.”

#### CAPÍTULO III - Da Contratação por Empresa Estrangeira

“Art. 14 - Sem prejuízo da aplicação das leis do país da prestação dos serviços, no que respeita a direitos, vantagens e garantias trabalhistas e previdenciárias, a empresa estrangeira assegurará ao trabalhador os direitos a ele conferidos neste Capítulo.”

❖ **Súmula 207 do TST - Conflitos de leis trabalhistas no espaço. Princípio da "lex loci executionis".** “A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação. **“CANCELADA EM 16/04/2012.**

□ Essa súmula seria correta se fosse aplicável para o empregado contratado por empresa estrangeira para trabalhar no exterior (art. 14 supramencionado)

□ Mas no caso do brasileiro, contratado por empresa brasileira, para prestar serviço –para esta- no exterior, não caberia. Isto em razão de que a Lei permite a escolha da norma pelo empregado

**D) princípio da condição mais benéfica ao trabalhador**

- A condição mais benéfica será aplicada independentemente de quando foi estabelecida
- Deve existir mais de uma condição benéfica viável para que se aplique o princípio
- Pode existir alteração quando for mais benéfico para o empregado
- Deve existir mútuo consentimento e não pode ocasionar prejuízo direto ou indireto ao trabalhador
- ex. 1. Empregado é admitido em 2015, constando cláusula de adicional de 150% de hora extra no contrato; em 2020, a empresa quer alterar para 50% do adicional de hora extra; veja que é um único contrato de trabalho em duas condições distintas; essa alteração de 2020 não tem validade jurídica, diante da condição mais benéfica; se fosse contratado com 50% e posteriormente fosse majorado para 150%, seria válido;
- Contrato de trabalho é um acordo de vontade que deve respeitar as normas mínimas; qualquer alteração deve surgir de um novo acordo de vontade (por isso a necessidade de mútuo consentimento)
- No exemplo acima, nem se o empregado concordasse, seria possível, já que violaria a condição mais benéfica (além da possibilidade de envolver coações, como a econômica: ou aceita ou é demitido) – violação do art. 468 da CLT
- Note que no exemplo anterior, tratava-se de um único empregado e de um único contrato de trabalho;
- ex.2. Empresa tem um regulamento interno, criado em 2000, que consta o adicional de 150% de hora extra, aplicável para todos os empregados da empresa; em 2020, a empresa altera esse regulamento para 50% do adicional; note a diferença para o primeiro exemplo, que falava do contrato de trabalho; essa alteração é válida, mas aplicável apenas para quem for contratado de 2020 para frente (os contratados anteriormente, continua aplicando a regra de 150%); a alteração, nessas condições, é válida ainda que resulte em supressão ou alteração de direito integralmente
- Veja que para violar o princípio, o empregado tem que ter experimento mais de uma condição (como no exemplo 1); no exemplo 2, os empregados contratados posteriormente à alteração, somente experimentaram essa condição de 50%
- **Art. 468 da CLT.** “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.”
- **Súmula 51, I do TST.** NORMA REGULAMENTAR. ART. 468 DA CLT. “As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.”
  - Veja que a súmula fala em efeitos
  - Pode suprimir direitos ou vantagens no regulamento
  - Mas os efeitos dessa alteração somente atingirão os contratados após a alteração

- Caso de acordo ou convenção coletiva (ultratividade da norma coletiva):
  - ex. Convenção Coletiva de trabalho assinada em 2019, com validade de 1 ano, prevendo hora extra com adicional de 70%; em 2020, próxima data base, não há renovação ou nova Convenção; esses efeitos permanecem após 1 ano, até que venha nova Convenção, ou, com o vencimento da validade, esses efeitos desaparecem?
  - **Teoria da incorporação**
    - As cláusulas de uma convenção coletiva, uma vez criadas, se desprendem daquele instrumento coletivo e passam a integrar o contrato individual de trabalho
    - Não se pode retirar essas cláusulas incorporadas do contrato, salvo em caso de rescisão (a retirada encontra óbice no art. 468)
    - Ou seja, no exemplo, permaneceria mesmo após 1 ano; os 70% continuam existindo para os empregados contratados dentro do lapso de validade; mesmo que venha uma convenção diferente
  - **Teoria da autonomia privada coletiva**
    - A própria CLT prevê o prazo de validade dos instrumentos coletivos, por essa razão, não se pode aplicar cláusulas coletivas por mais de dois anos
    - São aplicados enquanto em vigor a norma coletiva
    - As partes (destinatário da norma) possuem autonomia para definir a validade, não podendo o judiciário falar que vale por mais tempo; não se fala em incorporação no contrato de trabalho
    - **Art. 614, § 3º da CLT.** “Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.”
    - **TEORIA APLICADA** por lei
    - **Atenção:** veja que a reforma trabalhista vedou a ultratividade
  - **Teoria da incorporação limitada por revogação**
    - Os dispositivos de diplomas negociados vigoram até que novo diploma legal os revoguem
    - Ou seja, vigoram até que surja uma outra cláusula coletiva, seja revogando ou melhorando a situação
    - Pode ultrapassar o prazo de validade
    - Difere da primeira teoria: a primeira fala na incorporação do contrato de trabalho ilimitadamente (até morrer ou ser demitido); a teoria da incorporação limitada concorda com a ultratividade (pode continuar valendo), mas até que venha uma nova norma coletiva que revoga
    - A revogação pode ser tácita ou expressa
    - Adotada pelo Ministro Godinho
    - **Súmula 277 do TST** - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.” (CANCELADA PELO TST EM 30/06/2025)

- **obs. SÚMULA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF** (Foram mencionados os seguintes pontos: mudança de súmula sem precedentes que autorizariam a mudança; havia lei que adotava a teoria da incorporação, mas que foi revogada;)

STF - ADPF Nº 323/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES

Declara a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, nos termos do voto do Relator.

Brasília, Sessão Virtual de 20 a 27 de maio de 2022.

- **obs.** Essa súmula, em seu texto original, dizia o contrário: aplicava o princípio da autonomia privada coletiva: Súmula 277 do TST - Sentença normativa. Convenção ou acordos coletivos. Vigência. Repercussão nos contratos de trabalho

I - As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordos coletivos vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho.

II - Ressalva-se da regra enunciado no item I o período compreendido entre 23.12.1992 e 28.07.1995, em que vigorou a Lei nº 8.542, revogada pela Medida Provisória nº 1.709, convertida na Lei nº 10.192, de 14.02.2001.

## Bloco 5

▪ **Precedente Normativo n. 120:** SENTENÇA NORMATIVA. DURAÇÃO. POSSIBILIDADE E LIMITES (positivo) - (Res. 176/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011). “A sentença normativa vigora, desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos de vigência.”

### e) Princípio da primazia da realidade (primazia da realidade sobre a forma)

- Não dar tanto valor para a forma
- Documento pode gerar presunção absoluta ou relativa de veracidade
- Em regra, os documentos possuem presunção relativa, no direito do trabalho
- ex. em um processo que se discute horas extras, ainda que o empregador tenha cartão de ponto assinado pelo trabalhador, esse documento não gera presunção absoluta de veracidade; ou seja, é possível que o trabalhador produza prova para invalidar esse documento
- Isso ocorre, pois, o empregador pode manipular o documento ou exigir que o trabalhador preencha conforme a vontade imposta

- ex. empresário pede para os empregados que, quando der o horário de saída, passem o cartão de registro de saída, mas que voltem a trabalhar após passar o cartão
- Realidade tem prevalência sobre a forma
- Não se despreza o valor dos documentos, mas deve ser visto com reservas; deve, ao menos, permitir a produção de prova em contrário

- **SUJEITOS DO DIREITO DO TRABALHO**

- **Conceito de trabalhador:**

- É amplo
- Em princípio, toda pessoa física que prestar algum tipo de serviço
- Trabalhador é gênero
- Empregado é uma espécie de trabalhador

- **Questão teleológica do direito do trabalho**

- Leva em consideração uma espécie de trabalhador: o empregado
- Voltado para relações de empregado; não para relações de trabalho lato sensu

- **Conceito jurídico de empregado e seus requisitos:**

- “Art. 3º da CLT - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”
  - Elementos: Pessoa física, não eventualidade; subordinação; salário
  - Notam-se diversos requisitos para a caracterização de empregado

#### I- Pessoa Física

- Pessoa natural
- PJ jamais será empregada de alguém

#### II- Pessoalidade

- Pessoalidade na prestação dos serviços
- Na relação de emprego, o empregado assume o compromisso de prestar os serviços pessoalmente (não pode ser substituído por outra pessoa)
- Contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado

#### III- Não eventualidade

#### IV- Onerosidade (salário)

- O empregado trabalha mediante salário

- Pactuação de uma retribuição financeira do trabalho (não necessariamente o efetivo pagamento)
- Obs. A contraprestação pode não ser salarial, nesse caso não será empregado
  - ❖ Por isso a onerosidade é um fator importante para distinguir de outros trabalhadores, como por exemplo, do trabalhador voluntário
  - ❖ Mesmo que haja um pagamento para subsistência, deve-se atentar para a intenção contratual de trabalhar mediante uma paga remuneração

#### V- Subordinação (dependência; subordinação jurídica)

Obs. VI – Alteridade (não decorre do art. 3º)

- trabalho com responsabilidade de outro
- risco da atividade está com o empregador